

1500519-62.2021.8.26.0551
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/08/2022
... 200)

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500519-62.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500519-62.2021.8.26.0551
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2329896/2021 - DEL.POL.ARARAS, 21764369 - DEL.POL.ARARAS, 4771/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2329896 - DEL.POL.ARARAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Fernando Fernandes

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado FERNANDO FERNANDES, já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 3 de dezembro de 2021, por volta das 21h, defronte ao imóvel situado na Rua Ângelo Ferro, nº 24, Parque das Árvores, nesta cidade de Araras, Dario Pereira entregou para o réu, que trazia consigo e transportava, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar, em peso líquido, 40,57g (quarenta gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína, em duzentas e uma porções, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 34/35, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 36/37 e laudo químico toxicológico de fls. 134/137.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 202) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 190/199).

A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022 (fls. 231/232) e o acusado foi devidamente citado (fls. 274).

Instaurado incidente em relação ao corréu DARIO PEREIRA (fls.231/232), com desmembramento do feito.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu (fls. 299/301).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 297/298). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o benefício do tráfico privilegiado.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 40), pelo laudo químico toxicológico (fls. 141/142), pelas fotografias (fls. 46/58), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu Fernando Fernandes confessou os fatos, alegando que passava por necessidade.

A testemunha Jose Casemiro de Lima Junior confirmou a confissão, afirmando ter visto o réu recebendo drogas de outra pessoa e que ambos se assustaram ao ver a viatura. Realizada a abordagem, constatou que se tratava de pacote contendo drogas. Disse que o réu era o responsável por distribuir as drogas no bairro Jardim São João (fls.301)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Henrique Fernandes Vechietin(fl. 300).

São as provas dos autos. A condenação é de rigor.

De fato, o réu confessou e a confissão está amparada nos demais elementos colhidos nos autos.

Nesse sentido, os policiais deixaram claro terem abordado o réu em posse de quantidade relevante de drogas, presumindo-se a destinação ao tráfico. A presunção foi confirmada em juízo pela confissão.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que

merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

E mais: “O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

Já nos ensinava BECCARIA: “Determinar com precisão a credibilidade da testemunha e a qualidade da prova é um ponto importante em qualquer boa legislação (...) a verdadeira medida de sua credibilidade será na proporção ao seu interesse em declarar ou ocultar a verdade” (BECCARIA, Cessare, 1738-1794, Dos delitos e das penas. Tradução de Neury Carvalho Lima. São Paulo: Hunter, 2012; p.38)

Em outras palavras, André Estefam leciona que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55).

O ônus de prova tendente a desqualificar o testemunho do agente é da Defesa, que deverá trazer elementos concretos a desmerecer o testemunho prestado pelo agente estatal. Nada havendo em desprol do testemunho colhido, a prova deve ser considerada válida.

E mais: “O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

E mais.

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, “caput”, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

De fato, tratando-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado - que, segundo o Professor Damásio de Jesus, “são crimes em que o tipo faz referência a várias modalidades da ação” - o delito estará consumado com a prática de um ou mais de um dos verbos nucleares (Direito Penal, 10. Volume, Parte Geral, 6a. Edição, editora Saraiva, 1980, p. 200)

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do

tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denner de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Refuto, por fim, a alegação de estado de necessidade, eis que não demonstrada a situação de penúria financeira.

Nesse diapasão, como se sabe, "A prova da alegação" - lê-se no art. 156 do CPP - "incumbirá a quem a fizer;" (...) Trata o artigo supra do ônus da prova. As partes é que arcam com a obrigação de provas os fatos que alegam. Com uma diferença, porém. A prova da acusação há de ser plena e convincente, enquanto que para o acusado basta a dúvida, já que tem por si a presunção de inocência. Dispõe, com efeito, o art. 386, VI, do Código que o juiz absolverá o réu "se não existir prova suficiente para a condenação" (BARAUNA, José Roberto. Lições de Processo Penal, 2a. Edição, editora José Bushatsky. São Paulo, 1979, p. 1255)

Em outras palavras, "A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156 ...). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais (...)" (Curso de Processo Penal, 20a. Edição, ed. Saraiva, 2013, CAPEZ, Fernando, p. 410)

Assim sendo, uma vez alegado o estado de necessidade, caberá à Defesa demonstrar a concorrência de seus requisitos ou condições, a saber:

"Quatro condições, perante o Código vigente, são indispensáveis: a) existência de perigo atual para um interesse juridicamente protegido; b) não ter esse perigo sido provocado voluntariamente por quem invoca a justificativa; c) inevitabilidade do perigo; d) proporcionalidade entre a conduta do agente, ao salvar o direito, e a natureza do perigo que se lhe deparava" (GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal. Vol I. Tomo I, 4a. Edição, 22a. Tiragem. Editor Max Limond. São Paulo, p.292).

Entretanto, no caso em apreço, nenhuma das condições acima restou evidenciada pelos elementos probatórios dos autos. Os indícios aventados pelo agente sequer dúvida quanto a existência de estado de necessidade foram capazes de fazer emergir.

Logo, inviável acolher-se mencionada tese defensiva.

Almejando corroborar a fundamentação supra, transcrevo decisões de nossos Tribunais refutando a aplicação da excludente alegada em casos semelhantes. Vejamos:

“Invocar estado de necessidade em tráfico de entorpecentes, sobre constituir em subversão de valores juridicamente tutelados, fere o senso de justiça da comunidade”. (JTJ, 141/399)

“Dificuldade de subsistência por meio lícitos decorrentes de doença, embora grave, não justifica apelo ao recurso ilícito, moralmente reprovável e socialmente perigoso, de se entregar o agente a negociação de tóxicos” (JUTACRIM 25/214).

A condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. O réu é primário e possui bons antecedentes, portanto, fixo a pena-base em seu patamar mínimo.

Segunda fase. Inviável a redução com base na menoridade, eis que fixada no mínimo legal (aSumula 231, do STJ).

Terceira fase. Cabível a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da primariedade do acusado, no máximo legal.

O regime inicial deverá ser o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu FERNANDO FERNANDES, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber: a) prestação pecuniária de um salário mínimo, mediante depósito judicial, com destinação a ser definida nos termos das normas da Corregedoria do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) prestação de serviços à comunidade de forma a ser especificada pelo juízo das execuções criminais.

Poderá recorrer em liberdade.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03, lembrando que:

“Inviável a isenção do pagamento das custas processuais, porquanto a competência para apreciação de tal pedido é do Juízo das Execuções Criminais, por ocasião do pagamento, quando poderão ser aferidas as condições econômicas do réu, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil (que revogou o artigo 12 da Lei 1.060/50, anteriormente incidente ao caso): ‘vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário’. O mencionado dispositivo legal é aplicável subsidiariamente ao processo de natureza criminal, vez que inexistente, no Código de Processo Penal, dispositivo atinente à cobrança das taxas judiciárias processuais; o artigo 804 do Código de Processo Penal limita-se a indicar que o vencido será condenado às referidas custas, sem especificação do

procedimento atinente." (TJSP; Apelação Criminal 1501968-47.2018.8.26.0038; Relator (a): Marco de Lorenzi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022)

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos.

Com o trânsito em julgado; lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 21 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA